

1500804-73.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas.

Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista - SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500804-73.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-73.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NASCIMENTO DE SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de LUCAS NASCIMENTO DE SANTANA, na qual lhe é imputada a prática de infração penal artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06).

Narra-se na denúncia, em resumo, que "no dia 21 de julho de 2021, por volta de 12h20, na Rua Uruguai, altura do n. 280 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, LUCAS NASCIMENTO DE SANTANA, qualificado nos autos, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 25 (vinte e cinco) papérolas de cocaína, pesando aproximadamente 27,4g, e 20 (vinte) pedras de crack, pesando aproximadamente 4,7g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (fls. 110/111).

A denúncia foi recebida em 04/08/2021.

Promovida a citação (fls. 206), LUCAS NASCIMENTO DE SANTANA apresentou resposta à acusação (fls. 170/176).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/3), pelo laudo de exame pericial (fls. 154/156), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. Constam dos autos, ainda, os seguintes elementos probatórios: auto de exibição e apreensão às fls. 4/5, auto de constatação preliminar às fls. 6/7 e fotografias dos entorpecentes às fls. 28/29, fotografias do local no qual o acusado foi capturado (fls. 177-179) e imagem da câmera da rua na qual foi identificado o policial que realizou o flagrante, em frente à casa da genitora do acusado, em data diversa do crime - 21.3.2021 (fls. 180)

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Romário Costa de Souza (policial militar) relatou que se recorda dos fatos; que estava na companhia do motorista, Claudinei, em patrulhamento pelo bairro no Parque Hortênsia, que já é de conhecimento pelas ocorrências de tráfico de drogas; que avistaram na Rua Uruguai um indivíduo que deixava um beco, um acesso à residência; que no momento em que foi surpreendido pela equipe, tentou descer as escadas rapidamente e deixou cair dois papérols de cocaína, então foram ao encalço dele e o abordaram no escadão; que em revista pessoal localizaram cocaína, crack e certa quantidade de dinheiro em notas diversas; que, indagado, confessou a traficância no local; que, posteriormente, a equipe o identificou; que têm conhecimento de que ele tem envolvimento com tráfico e já tinham o abordado anteriormente em atitude suspeita mas nada foi localizado; que a Rua Uruguai é utilizada pelos traficantes como rota de fuga, tentando pular o telhado de pessoas; que posteriormente saiu a esposa dele da casa, a qual foi informada da ocorrência, e ele foi conduzido à delegacia, onde foi elaborado flagrante por tráfico de drogas; que não entraram na residência dele; que quando ele foi abordado ele confessou a traficância e informou que não tinha emprego e que precisava, tinha filho, tinha esposa; que sobre o dinheiro ele informou que era referente do tráfico, salvo engano tinha mil reais em notas diversas; que não se lembra se ele disse há quanto tempo ele estaria traficando; que, sobre a abordagem policial anterior, ele avisou a equipe na madrugada, se evadiu em um beco, foi abordado, mas nada foi localizado, e foi feita pesquisa, com constatação de passagens criminais, mas foi liberado; que não tem desavença com ele, só o conhecia da abordagem anterior; que, quando entraram na rua e viram Lucas, estavam próximos do numeral 200, e ele estava saindo desse beco e ao ver a equipe já retornou rapidamente, e foi nesse momento que caíram dois invólucros de cocaína, e depois constataram que havia o mesmo em seus bolsos; que o beco tem portão e dá acesso a algumas casas e também à Nações Unidas; que ele estava saindo desse portão e retornou; que estavam na viatura quando viram isso, em patrulhamento; que foi essa atitude suspeita de ver a viatura e rapidamente retornar; que foi então que foram ao encalço dele, e foi aí que ele deixou cair as porções de cocaína; que elas caíram bem na entrada desse portão; que ele morava nesse acesso onde o abordaram, tanto que a esposa dele saiu do local e compareceu à abordagem; que na via não havia mais ninguém na rua no momento da abordagem; que sobre as denúncias de colaboradores que não querem se identificar por represálias do tráfico, que é muito forte na Rua Uruguai, já receberam denúncias contra Lucas e diversos outros que realizam esse tráfico no Parque Hortênsia, Rua Uruguai, Paraguai, Rua Nações; que a abordagem policial anterior não tinha motivo para ser registrada na delegacia, apenas foi arrolado em relatório de abordagens da Polícia Militar; que não o conduziu à delegacia.

Já a testemunha Claudinei Gomes dos Santos (policial militar) relatou que se recorda da ocorrência; que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro Hortênsia, pela Rua Uruguai, local já bem conhecido como intenso ponto de tráfico de entorpecente; que pela altura do numeral 280 visualizaram um indivíduo que saía de “tipo” uma viela; que ele quando viu a viatura rapidamente voltou e deixou cair duas porções de cocaína no chão; que ele foi alcançado por seu parceiro e localizaram mais vinte e três porções de cocaína, totalizando vinte e cinco; que também localizaram vinte porções de crack, além de R\$ 1.058 em notas trocadas; que quanto ao dinheiro e à droga ele confessou que estava passando por problemas financeiros, não conseguia emprego, e tinha família para sustentar; que foi exarada voz de prisão e lidos os direitos constitucionais; que depois a esposa compareceu e ele foi conduzido ao plantão; que já o tinham abordado anteriormente, naquele mesmo local, na mesma rua, mas um pouco antes, uns 200 metros antes; que o contato anterior foi só nessa abordagem anterior; que têm denúncia dele já, mas a abordagem em si só foi essa, essa anterior e essa agora da prisão; que não tem desavença com o acusado; que, quando o viram, ele estava saindo de um beco, tipo uma viela, um corredor, acessou a calçada e, quando viu a viatura, voltou correndo, e deixou cair as duas porções de cocaína; que essa viela tem um portão que dá acesso a várias casas e também à rua de baixo, que é a rua Nações Unidas e depois à Rod. Dom Pedro, que costuma ser usada para se evadir das abordagens; que ele não fechou o portão, não deu tempo, ele só foi e voltou; que ele falou que morava naquele local; que ele informou que a viela dá acesso à residência dele; que não chegaram a entrar na residência dele, ele foi alcançado ainda no corredor; que ele falou que o dinheiro era do tráfico; que só fez orientações à esposa de Lucas, a qual ficou a todo momento calada.

Já a testemunha Wesley de Lima Arruda relatou que estava passando no beco, que é uma viela, tem fama de ser boca de fumo, então os policiais o viram e, pela sua passagem, que já pagou, pegaram-no e levaram-no; que os policiais perguntaram onde o Lucas morava; que conhece o Lucas de infância; que eles subiram o portão, pegaram o Lucas e o liberaram; que foi abordado, estava do lado de seu filho, que assustou e saiu correndo, então os policiais o pararam; que o portão estava fechado; que o policial que o abordou foi Romário; que foi tudo ao mesmo tempo, eles o enquadraram na viela, levaram-no próximo à casa do Lucas, perguntaram se ele o conhecia, depois subiram e o liberaram; que não viu se os policiais localizaram droga ou dinheiro; que só viu o momento em que ele subiu o portão, entrou na casa do Lucas, e voltaram com o Lucas, as drogas, o dinheiro; que não sabe quem estava na casa; que não tinha mais ninguém na rua, só praticamente ele mesmo e seu filho; que estava passando por ali, em horário de almoço; que não teve interesse em ir à delegacia; que já teve problema na justiça então achou que iria se prejudicar com isso; que de ter sido enquadrado até eles subiram o portão e entrar na casa do Lucas levou vinte minutos; que eles ficaram uns dez a quinze minutos; que entrou na casa o Romário e o outro ficou consigo; que está falando “eles” por modo de falar, mas só foi um que entrou na casa; que ficou com o outro policial a uns cinco metros do portão do Lucas, perto da viela; que seu filho tem onze anos; que na hora que ele viu a polícia ele saiu correndo, porque é muito medroso; que ele foi para a casa da sua mãe, porque ele viu a polícia e já saiu andando, correndo, e foi a hora que os policiais abordaram; que a casa da sua mãe fica na Rua Uruguai, umas dez casas para frente; que depois que a polícia liberou, foi para casa, não olhou para trás, foi para a casa da sua mãe; que na casa da sua mãe e de sua irmã contou a respeito dos fatos. Já a testemunha Bruna Ranieli Marques de Santana relatou que no dia exato era meio dia, ele chegou do serviço, trabalhando de autônomo, carpinteiro, chegou para almoçar, e escutaram um barulho no portão; que quando olharam era a polícia já chegando, gritando “o Lucas, o Lucas”; que ele já pegou Lucas e foi com ele para dentro; que ele pediu para colocar as crianças para dentro; que não passaram nem dez minutos, o Romário desceu, perguntou onde estavam as coisas do seu esposo; que viram o dinheiro; que falou que o dinheiro era dela, do bar; que disseram para ela que o dinheiro era dele, do tráfico; que Lucas tinha acabado de chegar, só foi o tempo de colocar a comida no prato; que essa escadaria só dá acesso à sua casa, e é todo fechado, é individual; que a polícia disse que o dinheiro era do tráfico e

perguntou “como assim?”, e nisso ele entrou na viatura e foi preso; que quando subiu Wesley não estava mais na rua; que Romário entrou na sua casa; que já o conhecia de vista, porque uma vez ele abordou o seu marido; que sabe o nome dele pelo crachá da camisa dele, em que havia o “R” de Romário; “R. Costa”; que chegou no dia da audiência e viu que era Romário, Romário Costa; que só ele invadiu a casa; que na hora que subiu ele falou “acalma as crianças”, então ficou embaixo, e em poucos minutos ele já desceu, mexeu nas coisas de seu marido, achou o dinheiro; que bem mais pra frente havia pessoas olhando no portão; que umas dez casas antes havia pessoas que viram a invasão à casa; que em nenhum momento viu droga com seu marido; que um dia antes, estava com o bar aberto, e o dinheiro era para pagar o aluguel; que o policial só deixou R\$ 200,00; que havia dois policiais no local; que Wesley é conhecido dele de infância, a mãe dele mora lá na rua; que não foi à delegacia porque seus sogros foram até à delegacia; que seu sogro foi e daqui a pouco falou que ele tá preso por tráfico de drogas; que ninguém se intromete lá, porque a rua lá é bem conhecida; que não quis ir à delegacia para noticiar essa ilegalidade, porque já sabiam que ia ter a audiência; que havia dinheiro em espécie, R\$ 1.500,00, do bar; que era o dinheiro de três dias, porque lá é mais fim de semana, e se não me engano a abordagem foi na quarta; que teve que entregar o bar; que o vencimento era bem no dia; que o vencimento era mensal no dia 21; que a locadora era a Natália; que contou essa história; que o dinheiro era para o bar e para comprar os mantimentos, tipo cerveja; que ela falou que poderia ajudar, para comprovar que o dinheiro era dele, mas não pediu para ela; que o aluguel era R\$ 900,00; que Romário só entrou com a arma; que não viu droga em nenhum momento; que no dia da abordagem ele estava em horário de serviço, trabalhando para o Ricardo; que Ricardo mora na Cachoeirinha, uns dois bairros depois; que Ricardo também fez os papéis comprovando que ele estava trabalhando; que Lucas já esteve envolvido há dois anos atrás, mas depois que ele saiu mudaram de vida e ele estava tentando mudar; que têm três filhos.

Por fim, o acusado Lucas Nascimento de Santana relatou que no dia dos fatos tinha acabado de chegar em casa, na hora do almoço, seu patrão tinha chegado lá, desceu em casa para almoçar, passaram dez vinte minutos no máximo, escutou um barulho no portão; que a criançada tem costume de jogar bola no portão, então achou que seriam elas, mas já ouviu uma voz de homem perguntando por “Lucas”, e ela respondeu que sim, que era o esposo dela; que levantou para ver e já viu Romário descendo as escadas falando que estava preso por tráfico de drogas; que suas crianças começaram a chorar; que ele falou para colocar as crianças para dentro; que ele falou para sua esposa entrar com as crianças; que nisso foi com Romário e ele falou “eu não falei que ia te prender? E palavra de homem não faz curva”; que ele abriu o portão, viu a viatura parada na frente de casa, acha que com Claudinei e Wesley, sentado; que nisso Romário perguntou se conhecia Wesley, falou que conhecia, mandou Wesley ir embora e o colocou algemado na viatura falando que estava preso; que ele desceu em casa novamente, ficou dez minutos em casa, e subiu com o dinheiro e as drogas, falando que ia ser conduzido por tráfico de drogas; que Romário entrou duas vezes na sua casa; que nessas duas vezes a sua esposa estava lá dentro; que foi a esposa que atendeu do corredor, até que ele pediu que ela entrasse com as crianças para dentro; que as crianças estavam na porta, na cozinha; que assim que sua esposa entrou e começou a subir com ele; que Romário pegou a chave da porta de casa, subiu a escadaria; que Romário não chegou a entrar na casa da primeira vez, porque ele já veio gritando e foi até a porta; que Romário falou “cadê a droga?” e suas filhas começaram a chorar; que Romário já tinha o abordado outras vezes e já sabia o nome dele pela tarjetinha; que ele o abordou umas duas ou três vezes; que quando ele viu que tinha uma passagem, tinha saído há um ano da Penitenciária de Guaraí; que o dinheiro foi apreendido dentro de casa, acha que dentro do guarda-roupa, salvo engano R\$ 1.500,00; que o dinheiro é de sua esposa, a qual tinha um estabelecimento, um bar; que em março Romário não chegou a abordá-lo, e ele sempre sondava a rua de viatura; que ele já o abordou sozinho; que foi abordado por Romário quando estava com um ano e dois meses na rua e outras duas vezes antes de ser preso no mês sete, e isso foi no mês cinco e no mês seis; que as abordagens começaram em abril; que foi solto em 15 de janeiro de 2020.

Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem do acusado e quanto à apreensão da droga em sua posse.

De outro lado, observa-se que foi ventilada em defesa a tese de negativa de autoria, a qual, porém, está desprovida de elementos que lhe confirmem aceitabilidade e verossimilhança e acaba se revelando divorciada das demais provas produzidas, as quais confirmam de modo íntegro e coerente a hipótese acusatória. Quanto à hipótese alternativa ventilada pela defesa, verifica-se que os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado possuem inúmeras inconsistências entre si e também que havia outras fontes de provas disponíveis à defesa, notadamente testemunhas, que, no entanto, não foram arroladas para oitiva em audiência sob o contraditório.

Com efeito, em primeiro lugar, verifica-se que a testemunha Wesley relatou que estava em via pública, em pleno horário de almoço, e que se passaram vinte minutos desde o momento em que foi “enquadrado” até que os policiais foram à casa de Lucas e mais dez a quinze minutos dos policiais dentro da casa de Lucas, mas que – de forma inverossímil – só havia ele próprio na rua no momento. Destacou, ainda, que seu filho de onze anos estava consigo e que, ao ver a polícia, correu para a casa de sua mãe, por sentir medo, de modo que não presenciou a abordagem policial. No ponto, nota-se que a simples presença da polícia, ainda antes de efetuar qualquer abordagem policial, em regra não desperta o receio de crianças, salvo se houvesse algum fato anterior a justificá-lo (v.g. presença de ato anterior de abuso ou violência), o que, no entanto, não foi indicado no caso a fim de tornar verossímil a narrativa em tela. Expôs que contou então o fato à sua mãe e à sua irmã. Nenhum dos três, porém, foi à delegacia para relatar o que viram à autoridade policial, tampouco procurou qualquer outra autoridade constituída.

Vale notar que Wesley disse que se passaram dez a quinze minutos até que Romário e Lucas saíssem da casa, o que então só teria ocorrido por uma vez. No entanto, Lucas relatou que Romário ingressou na sua residência por duas vezes. Wesley começou seu depoimento dizendo que “eles” subiram o portão, pegaram o Lucas e o liberaram (no plural), mas depois disse que foi só Romário que entrou na casa. Indagado sobre a inconsistência, disse que “eles” seria apenas um modo de dizer.

De outro lado, vale notar que a informante Bruna relatou que a sua casa foi invadida de inopino pelo policial Romário, que chegou quando Lucas tinha acabado de chegar e só foi o tempo de colocar a comida no prato. Já Lucas, em interrogatório, disse que estava em casa para o horário de almoço e, só depois de vinte minutos, o policial Romário chegou. A informante Bruna também relatou que o policial pediu para que ficasse com as crianças dentro da casa e que, depois de dez minutos é que Romário retornou, dizendo que ele seria preso por tráfico de drogas. Entretanto, o acusado Lucas relatou que, logo que Romário chegou, já disse que ele estava preso por tráfico de drogas, razão pela qual as crianças começaram a chorar, o que não havia sido relatado por Bruna. Noutro plano, vale notar que Bruna disse que a invasão domiciliar foi presenciada por várias pessoas na rua (nenhuma delas indicada como testemunha), ao passo que Wesley disse que estava sozinho na rua. Bruna disse que não viu droga nenhuma, embora tivesse sempre dentro da casa. Já Wesley disse que o policial saiu com Lucas com a droga e com o dinheiro. Por fim, vale observar que Bruna disse que sabia que o policial Romário tinha esse nome por causa da tarjeta; depois, esclareceu que na tarjeta só havia o nome “R. Costa”; depois, disse que ficou sabendo que “R. Costa” ao no dia em que recebeu o “papel da audiência”, mas no mandado de fls. 189 não consta o nome das demais testemunhas (nem, inclusive, o de Romário).

Verifica-se que Bruna e Lucas relataram duas testemunhas, sem vínculo afetivo com nenhum dos dois, que pudesse vir a depor em juízo para corroborar a versão defensiva: (1) Ricardo, o empregador de Lucas, que poderia confirmar a versão de que ele estava trabalhando no dia; e (2) Natália, a locadora do bar, que poderia confirmar a versão de que o aluguel de R\$ 900,00 tinha vencimento no dia 21 e seria pago em dinheiro em espécie. Nenhum dos dois, porém, foi arrolado para oitiva como testemunha.

Ainda, embora Bruna tenha narrado que a escadaria é fechada e só dá acesso à sua rua, vale observar que as fotografias de fls. 177-179 são inaptas à demonstração do

alegado: as fotografias demonstram apenas a via pública, sem demonstrar a escadaria. De outro lado, a declaração de fls. 239 configura prova anômala e possui reduzido valor probatório - a testemunha deveria ter sido arrolada para oitiva em audiência, sob o crivo do contraditório. Não bastasse, o horário constante da declaração (até 12h) não infirma a hipótese acusatória (abordagem policial e apreensão da droga às 12h20).

Nesse rumo, a hipótese alternativa ventilada, de flagrante forjado, pelos policiais responsáveis pela abordagem, é dotada de reduzida verossimilhança, tendo em vista que Bruna e Wesley afirmam que os policiais chegaram ao local no horário de almoço, sem droga alguma e, após invadirem a casa deste (entrando no local inclusive por duas vezes, conforme relato do acusado, e na presença de vários transeuntes, conforme relato de Bruna), é que apareceram com as drogas - que foram vistas por Wesley, que estava na rua, mas não foram vistas por Bruna, que estava na casa. Logo, não há coerência interna da própria narrativa, tampouco coerência externa com os demais elementos probatórios trazidos aos autos, notadamente a apreensão de dinheiro em espécie e de droga em via pública e no horário do dia (horário de almoço) e os depoimentos policiais detalhados e desprovidos de contradições internas.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que o acusado concorreu para a prática do tráfico de drogas. Registre-se que a circunstância de o acusado ser usuário de drogas e de exercer trabalho lícito não afastam por completo a possibilidade de, paralela e concomitantemente, concorrer para o tráfico de drogas.

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga

transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de transportar, como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que o acusado praticou conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes demonstra a existência de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), a qual também configura reincidência (CP, art. 64). Assim, a fim de evitar punição dúplice pelo mesmo fato (*bis in idem*), tal registro negativo será considerado apenas como reincidência na segunda fase, sem produzir efeito nesta primeira fase (cf. Súmula 241/STJ). Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), devem ser valoradas negativamente. Quanto à natureza da droga (cocaína e crack), trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga, verifica-se que não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita suficiente para a elevação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Assim, a pena-base deve ser agravada em 1/6 (um sexto), conforme referencial jurisprudencial.

Na segunda fase da dosimetria, não há limites legais mínimo e máximo de agravamento ou atenuação de pena previamente estipulados nos arts. 61 a 66 do CP. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação da fração de 1/6 como patamar mínimo das causas de aumento/diminuição de pena constantes do Código Penal, consolidou-se a fixação da fração de 1/6 como referencial para o agravamento ou atenuação da pena em razão de cada circunstância legal, de modo que "a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021).

Assim, a pena intermediária é fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida no patamar da pena provisória.

Por tais razões, fixa-se a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 729 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à

época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve ser atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado, com base no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP e observadas as Súmulas 718 e 719/STF e 269 e 440/STJ.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu em razão da reincidência. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado LUCAS NASCIMENTO DE SANTANA ao cumprimento de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do CP.

Quanto à manutenção prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do acusado. Recomende-se ré o réu na prisão em que se encontra.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único). Quanto à arma de fogo e às munições apreendidas, deve ser decretada a perda em favor da União. Encaminhem-se ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento



das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º). Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP. Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020). Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Nazaré Paulista, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA